

1501621-70.2021.8.26.0535
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Resistência
Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO
Comarca: Arujá
Foro: Foro de Arujá
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 11/11/2022
... procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas pelo acusado Andrew está demonstrada conforme boletim de ocorrência, laudo de constatação e prova oral colhida.

A autoria de delito de tráfico de drogas pelo réu Andrew também restou comprovada.

Contudo, no que se refere aos delitos de associação para fins de tráfico e resistência, inexiste prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Arujá
Foro de Arujá
1ª Vara
Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1501621-70.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501621-70.2021.8.26.0535
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Resistência
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
ANDREW VINÍCIUS DE ALMEIDA SANDIM e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

ANDREW VINÍCIUS DE ALMEIDA SANDIM e MARCOS HENRIQUE CAMPANA DA CRUZ, qualificados no autos, foram denunciados pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c.c. art. 35, ambos da Lei 11.343/06, e o primeiro, ainda, pelo art. 329, do CP, na forma do art. 69, do CP com os demais delitos, porque no dia 16 de junho de 2021, por volta das 11:15 horas, na Rua Três, altura do número 167, nesta cidade, teriam se associado entre si e com terceira pessoa desconhecida para o fim de praticar reiteradamente ou não o delito de tráfico de drogas. Consta também que na mesma data e local traziam consigo para fins de venda a terceiros, 87 eppendorfs de cocaína (15,3 gramas - massa líquida) e 32 porções de maconha (32,2 gramas - massa líquida), sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico, drogas essas que causam dependência física e psíquica. Ainda, no mesmo local e tempo, o acusado Andrew se opôs à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo.

Narra a acusação que os acusados se uniram com terceira pessoa conhecida como "Dih"

para realizar tráfico de drogas na região do Parque Rodrigo Barreto, e providenciaram um local para o comércio de drogas, dividindo funções, sendo que Marcos e "Dih" seriam os responsáveis por recepcionar usuários e encaminhá-los à Andrew, que entregava entorpecentes a adquirentes. No dia dos fatos, os acusados foram avistados pela polícia civil que realizava operação para coibir tráfico no local. Após campana de cerca de 40 minutos, os policiais decidiram abordar os acusados e Andrew resistiu à prisão, agredindo o policial Leonardo, lesionando-o. Com o acusado Marcos não foi localizado nada de ilícito e "Dih" se evadiu do local e não foi mais localizado. Um usuário, ainda, estava perto do local e com ele foi localizado um cigarro de maconha. Os acusados foram presos em flagrante.

Auto de Prisão em Flagrante Delito às fls. 01/02. Boletim de Ocorrência às fls. 03/06. Auto de exibição e apreensão às fls. 13/14. Laudo de constatação (fls. 33/38).

Em audiência de custódia foi concedida liberdade provisória ao acusado Marcos, sendo convertida em preventiva a prisão em flagrante do réu Andrew (fls. 63/67).

Laudo definitivo de fls. 101/103.

Notificados, os réus apresentaram defesa preliminar às fls. 121/126 e 145.

A denúncia foi recebida em 09/02/2022, às fls. 146/147.

Laudo pericial de fls. 204/205.

Em audiência foram ouvidas testemunhas e interrogados os acusados (fls. 237/243), sendo acolhido pedido ministerial e concedida a liberdade provisória ao acusado Andrew, com imposição de outras medidas cautelares.

O MP em alegações finais orais, pugnou pela procedência parcial da denúncia. Altercou que o réu Andrew confessou os fatos e sua autoria é patente, diante também de demais provas. Em relação ao delito do art. 329, do CP, contudo, não se narrou exatamente como foi a resistência, uma vez que a tentativa de desvencilhar dos policial não seria delito, e o réu tinha lesão no olho, indicativo de que foi lesionado pelos policiais. Sustentou ser caso de ofício à Corregedoria de Polícia. Em relação ao réu Marcos, afirmou que não há provas de que ele cometeu o delito de tráfico, pois o réu Andrew afirmou que o desconhecia, e os policiais afirmaram que o réu seria "olheiro", e não teria visto a polícia, mas também era o réu Marcos pessoa que indicava os demais traficantes a usuários. Alegou existir dúvida se ele efetivamente traficava drogas e deve ser absolvido. Alegou que diante de absolvição de Marcos, mesmo diante de existir outro indivíduo, não há provas de caracterização de delito de associação para fins de tráfico. O réu Andrew ainda faria jus à atenuante de confissão e de benefício de tráfico privilegiado, com regime aberto e substituição da pena por restritiva de direitos, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.

Em alegações finais de fls. 249/275, a defesa do acusado Marcos requereu a absolvição do acusado, por não ter ele praticado o delito e pela ausência de provas de conduta delitiva. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de porte para uso próprio e, ainda, em caso de condenação, pugnou pela fixação de regime aberto e substituição por restritiva de direitos, sendo reconhecido, ainda, o tráfico privilegiado.

Em alegações finais, a defesa do acusado Andrew, às fls. 279/285 requereu a aplicação da atenuante da confissão, sendo reconhecido o tráfico privilegiado e ainda, descontado o tempo de prisão cautelar. Pugnou por regime aberto e substituição por restritiva de direitos.

Os autos vieram conclusos para sentenciamento.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas pelo acusado Andrew está demonstrada conforme boletim de ocorrência, laudo de constatação e prova oral colhida.

A autoria de delito de tráfico de drogas pelo réu Andrew também restou comprovada.

Contudo, no que se refere aos delitos de associação para fins de tráfico e resistência, inexistente prova de materialidade e autoria, e em relação ao acusado Marcos, inexistente prova de autoria do delito de tráfico de drogas.

Passo à análise da prova oral colhida no feito:

A testemunha André Alves de Souza declarou que é policial civil e na data dos fatos estava em diligências para coibir tráfico de drogas e rumaram a pontos de incidência de tráfico e ao passar no Bairro Barreto, Rua 3, viram indivíduos parados e em veículo descaracterizado ficaram observando, percebendo a dinâmica dos fatos. Marcos recepcionava os usuários e apontava para um indivíduo de cabelo vermelho, que os réus informaram o apelido. Um outro indivíduo estava sentado numa pedra, que era Andrew, que entregava algo às pessoas. Ficaram cerca de 40 minutos vendo a dinâmica do tráfico e viram cerca de oito usuários no local. Disse que fizeram planejamento e cada policial abordou um indivíduo. O indivíduo de cabelo vermelho correu. Marcos era o "olheiro" e depois auxiliou o policial Leonardo que tentava algemar o réu Andrew, que vendia as drogas. Andrew se debatia com força contra o policial. Disse que houve a vinda de mais veículos em apoio. No bolso de Andrew havia maconha, cocaína, celular e contabilidade de tráfico. O réu Andrew informou que achava que era procurado e por isso exerceu força contra o policial Leonardo. Declarou que reconhece os acusados como aqueles que abordaram. Disse que o policial Leonardo tentava conter e algemar Andrews, mas teve que ajudar. Marcos ficava como uma "parede" para fazer filtro e dava alerta quando a polícia chegava. Ele estava a dez ou quinze metros dos outros dois indivíduos. Quem empreendeu fuga era quem recebia o dinheiro.

A testemunha Rafael Coutinho declarou que no dia dos fatos estava com Leonardo e André e foram à rua 03, local de ponto de drogas. Disse que se distanciaram a 30 metros do local em carro descaracterizado, por cerca de meia hora e viram movimentação de tráfico, especificamente por 3 indivíduos, que era o olheiro, quem vendia e quem entregava. Declarou que entre sete ou oito usuários encostaram no local e se serviram de drogas. Disse que resolveram abordar, cada um iria abordar um indivíduo. Um deles se evadiu e seria o vulgo "Di". O outro resistiu à prisão e deu trabalho para o policial Leonardo, que contou com a ajuda de André. Leonardo ficou com o dedo fraturado. Abordou o "olheiro" que era o réu Marcos, que nada de ilícito havia com ele. Ele confessou naquele momento, confessando o tráfico. Jonathan apareceu e foi relacionado como usuário, pois tinha com ele um cigarro de maconha. Levaram os três à delegacia. Afirmou que reconhece os dois acusados em audiência. Disse que o Marcos era o primeiro indivíduo a recepcionar as pessoas que compraram entorpecentes, indicando Andrew e este indicava o "Di". Não necessariamente nessa ordem, mas o réu Marcos era quem recepcionava as pessoas. Marcos estava a dez ou quinze metros dos demais indivíduos. Em relação à resistência do Andrew, não pode ver muito, pois estava abordando Marcos. Mas sabe que ao chegarem os policiais, perto de um matagal, onde era fácil a fuga, "Di" fugiu e o Andrew resistiu e os dois policiais o jogaram ao solo, com risco dele tomar a arma. Afirmou que Andrew cometeu uma agressão, tentando se desvencilhar do policial com os braços. Declarou que o réu Andrew fez movimentos bruscos com os

braços e Andrew não era menor que o policial Leonardo, sendo maior do que este. Narrou que em relação à vídeo que o réu Andrew iria confessar e dizer que era culpado, afirmou que desconhece esse fato.

A testemunha Leonardo Oliveira de Holanda declarou que é policial civil e na data dos fatos estavam em operação contra tráfico de drogas e foram à rua 03, local de traficância. Disse que estava em companhia de Rafael e André e observaram a dinâmica do tráfico em viatura descaracterizada. Um indivíduo com blusa Adidas e alargador, com piercing no nariz recepcionava as pessoas, iam para outro indivíduo moreno e ao final a outro que estava sentado e entregava algo a pessoas. Viu seis usuários irem a tais indivíduos. No momento da abordagem um deles se evadiu e Andrew resistiu à prisão, lesionando sua falange do dedo médio, ficando dois dias afastado das funções. Contiveram o réu Andrew e ele foi levado ao solo e algemado. Com ele havia maconha e cocaína. Rafael abordou o corréu que usava blusa Adidas, que era o Marcos. Este falou que era "olheiro". Depois apareceu Jonathan que trazia um cigarro de maconha e falou que era usuário. Andrew era quem entregava a droga aos usuários e ele tinha em seu poder manuscritos de tráfico de drogas. Marcos era o "olheiro", ficando antes de quem efetivamente vendia as drogas, direcionando os usuários aos demais indivíduos que não tinham visão plena de quem se aproximava do ponto de drogas. A campana durou cerca de 30 a 40 minutos. Houve a apreensão de celulares e foi solicitada a quebra de sigilo, mas não sabe o que ocorreu. Afirmou que não pediu para Andrew confessar em vídeo que traficava drogas. Ele confessou os fatos após a resistência, pois o réu imaginava que era procurado por tráfico. Depois ele pediu desculpas e falou que o dinheiro da venda de drogas era para sustento de seu filho. Afirmou que no dia dos fatos o Andrew foi fotografado e não tinha hematomas na face. Disse que era impossível imobilizar o réu Andrew sem levá-lo ao solo e as lesões se deram pela resistência do réu, tanto que também se lesionou. Desconhece a lesão no olho de Andrew. O réu estava ao final da via onde havia entulhos. Também ficou lesionado em razão da resistência do acusado. Com Marcos não havia nada de ilícito. Entre Marcos e os demais havia distância em torno de 15 metros.

O acusado Andrew Vinicius Almeida declarou que tem 24 anos, era office boy antes de ser preso e não estava registrado, pois trabalhava na imobiliária do pai e ele pagava R\$ 1.600,00. Ia começar a fazer faculdade, mas aconteceu isso. Era casado e não é mais após a prisão. Tem um filho. Já foi processado por tráfico de drogas. Disse que realmente estava traficando, é culpado e se arrepende muito. Disse que destruiu família e era também usuário. Afirmou que seu filho está com 4 anos e somente no aniversário de dois anos estava com ele. No dia que foi preso, não reagiu a princípio quando os policiais chegaram. Não correu e foi algemado pelo policial, falando que não sabia onde era a "casa bomba" o policial chutou suas pernas e caiu no chão, batendo o rosto no chão, motivo pelo qual chutou o policial também e apareceu outro policial e o pegou pelo pescoço, aí o outro policial lhe bateu e deu um chute nele. Disse que tinha umas 50 porções de maconha e noventa porções de cocaína. Afirmou que não conhece o corréu Marcos e não chegou a vê-lo. A rua 3 é reta e no final tem um lugar que não passa carro, e não conseguem ver a rua. Disse que o corréu deveria estar na outra rua, mas não o viu. Não estava trabalhando com ele.

O réu Marcos Henrique Campana da Cruz declarou que tem 22 anos, trabalha como designer gráfico, é técnico, ganha em torno de R\$ 2.000,00 ao mês. Não tem filhos, mas cuida de três irmãos mais novos e que dependem dele. Não foi processado antes. Em relação aos fatos declarou que não estava no local de olheiro, pois ia comprar uma "paranga", mas não tinha todo o dinheiro. Disse que perguntou a quem vendia, que não era o Andrew, se fariam um preço mais baixo e ele disse que ia ver. Ficou meia hora ali esperando e os policiais apareceram no local e teve toda essa cena que falaram. Afirmou que queria comprar mais barata a maconha. Não viu a prisão do Andrew, mas ele estava com o supercílio rasgado e quando foram na delegacia e ele ficou com o olho todo roxo. Narrou que não ficava indicando para as pessoas quem

estava vendendo as drogas. Disse que não tinha visto Andrew antes e o viu na hora que os policiais apareceram com ele e o colocaram na viatura. Disse que quando os policiais o pegaram, um deles o ameaçou e disse que teria que confessar. Disse que não ia confessar e somente falaria com seu advogado. Afirmou que não se recorda o policial que o ameaçou, e outro intercedeu para que não fosse agredido, mas quem ameaçou foi um daqueles que estava na apreensão. Declarou que seu trabalho o estressa e por isso não consegue lembrar de várias coisas.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Pela prova colhida nos autos, não há certeza de que o réu Marcos possuía drogas para fins de tráfico. Em relação ao corréu Andrew, contudo, há prova suficiente para o édito condenatório em relação ao delito de tráfico de drogas.

Primeiramente, anoto que o laudo pericial acostado às fls. 101/103 confirmou a natureza entorpecente das drogas encontradas.

Em seu interrogatório, como se pode observar, o réu Marcos negou a prática do delito de tráfico, alegando que foi ao local dos fatos adquirir uma “paranga” de maconha, mas queria pagar preço menor, o que disse a pessoa que ali se encontrava. Tal pessoa teria pedido para o réu aguardar e afirmou ter ficado no local por cerca de 30 minutos aguardando “desconto” para a compra de maconha. Negou ter confessado que realizava tráfico de drogas e disse ter sido ameaçado por um dos policiais para que confessasse a autoria delitiva.

Os policiais narraram como abordaram os acusados na data dos fatos, indicando terem visto o réu Marcos próximo de outro indivíduo, vulgo “Dih” e do corréu Andrew, em distância de 15 metros aproximadamente. Afirmaram que o réu Marcos seria “olheiro” e que também tinha a função de encaminhar compradores de drogas aos demais indivíduos que as vendiam. Informaram que após a abordagem, nada de ilícito havia com Marcos e ele teria confessado informalmente o tráfico de drogas.

O réu Andrew nega que Marcos traficava drogas conjuntamente com ele, dizendo que não o viu no local dos fatos. Andrew confessou que realizava tráfico de drogas no local, tendo consigo porções de maconha e cocaína.

Em sede policial os acusados permaneceram em silêncio (fls. 22/23).

O Ministério Público em sede de alegações finais orais pugnou pela absolvição do réu Marcos, por entender que inexistem provas suficientes para a condenação.

Realmente, em relação ao réu Marcos, com efeito, no caso sub judice, efetivamente de relevante existe apenas sua abordagem pela polícia em local próximo de onde estava o corréu Andrew e outro indivíduo, não havendo quaisquer outros indícios que apontem que o réu Marcos efetivamente realizava tráfico de drogas no local.

Observo, como bem pontuou o Parquet, que os policiais afirmaram que Marcos seria “olheiro”, contudo, mesmo tendo suposta função, não teria notado a presença de polícia que realizava campana próximo ao local. Ademais, os policiais, além de atribuírem função de “olheiro” ao réu Marcos, também disseram que este teria outra função, qual seja, de encaminhar usuários à “Dih” e ao corréu Andrew, o que se revela contraditório.

O réu Marcos foi firme ao afirmar que somente teria ido ao local para adquirir maconha, sequer a comprando, e que permaneceu esperando para conseguir pagar valor mais baixo pelo entorpecente.

Vê-se que, de todo modo, pela prova colhida nos autos, não há certeza de que o réu Marcos estava traficando drogas no local dos fatos.

Cabe observar que o réu Marcos, como dito, negou que traficava drogas com veemência e o interrogatório do corréu Andrew, como dito, aponta que os acusados não se conheciam.

Como sói ocorrer, não foi trazida qualquer outra testemunha, que estivesse presente no momento em que houve a abordagem dos acusados, não sendo ouvido em juízo também pessoa de nome Jonathan, que estaria perto do local e seria usuário.

É importante salientar que em delitos de tráfico de drogas, cometidos, normalmente, na clandestinidade, a prova, em regra, é composta por depoimentos dos policiais, que de modo geral, são suficientes a demonstrar a culpabilidade de um réu, desde que em consonância com as demais provas carreadas aos autos. A presente situação não se amolda, todavia, a esta regra, lembrando que o réu Marcos negou o tráfico de drogas, não havendo, do mesmo modo, outros indicativos seguros da ocorrência do comércio espúrio pelo acusado.

Não se trata aqui, de forma alguma, de desqualificar todo e qualquer testemunho prestado por policiais, mas de não olvidar ou ignorar o julgador a possibilidade de ocorrência de falhas perpetradas por estes no exercício de sua função, que podem até incluir imputações precipitadas, pouco apuradas, apressadas.

Nessa toada, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - NECESSIDADE - PALAVRA ISOLADA DOS POLICIAIS. A versão policial isolada sobre a prática do crime não forma conjunto probatório suficiente para sustentar a convicção sobre a destinação da droga apreendida e, portanto, não autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas. (TJMG - Apelação Criminal 1.0699.16.010381-7/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 03/12/2018).

Neste sentido também é o ensinamento de Gustavo Badaró:

Quanto ao testemunho dos policiais, há correntes radicais, que, pelo seu próprio extremismo, devem ser descartadas. Uma dessas correntes entende que o fato de a testemunha ser policial, por si só, não a torna impedida de depor, não havendo qualquer disposição legal neste sentido. Ao contrário, o policial não se enquadra nas hipóteses do artigo 207 do CPP, devendo ser dado ao seu depoimento o mesmo valor de qualquer outra testemunha. De outro lado, há corrente oposta, no sentido de que os policiais, pela simples condição funcional, seriam suspeitos. Deve prevalecer uma posição intermediária: se os policiais não podem ser considerados suspeitos, pelos simples fato de serem policiais, por outro lado, é inegável o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos investigatórios praticados, pelo que seus depoimentos têm valor relativo, devendo ser cotejados com outros elementos de provas existentes nos autos, em especial o testemunho de pessoas estranhas aos quadros da polícia. Não se pode esquecer que as testemunhas são, por definição, terceiros imparciais, sem qualquer interesse no processo, o que não é exatamente o caso dos policiais em relação aos crimes por ele investigados. Por tais motivos, não se deve admitir que seja proferida uma sentença condenatória com base exclusiva no depoimento de policiais, ainda que estes se demonstrem harmônicos entre si (BADARÓ, Gustavo Henrique; Processo Penal. São paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 477/478). (Grifos nossos)

Em sentido semelhante ao aqui exposto, esclarece, de forma muito didática, Aury Lopes Jr:

Da mesma forma, não há que se falar em restrição ao depoimento dos policiais. Eles podem depor sobre os fatos que presenciaram e ou dos quais têm conhecimento, sem

qualquer impedimento. Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é evidente que o envolvimento do policial com a investigação (e prisões) gera a necessidade de justificar e legitimar os atos (e eventuais abusos) praticados. Assim, não há uma restrição ou proibição de que o policial seja ouvido como testemunha, senão que deverá o juiz ter muita cautela no momento de valorar esse depoimento. A restrição não é em relação à possibilidade de depor, mas sim ao momento de (des)valorar esse depoimento.

Contudo, é recorrente o Ministério Público arrolar como testemunhas apenas os policiais que participaram da operação e da elaboração do inquérito. Busca, com isso, judicializar a palavra dos policiais para driblar a vedação de condenação "exclusivamente" (art. 155 do CPP) com base nos elementos informativos colhidos na investigação. Na continuação, deparamo-nos com sentenças condenatórias em que são utilizados os elementos do inquérito e o depoimento dos policiais em juízo. No fundo, é um golpe de cena, um engodo, pois a condenação se deu, exclusivamente, com base nos atos da fase pré-processual e no depoimento contaminado de seus agentes, natural e profissionalmente comprometidos com o resultado por eles apontado, violando o disposto no art. 155 do CPP. Portanto, se não há impedimento para que os policiais deponham, é elementar que não se pode condenar só com base nos seus atos de investigação e na justificação que fazem em audiência." (2019, p.462)

Aliás, na linha do que está sendo exposto, se a ideia fosse tomar como absoluta e incontestável toda e qualquer declaração prestada por testemunhas policiais no bojo do processo penal, despicienda seria a instrução probatória e até mesmo a valoração da prova colhida pelo Juiz de Direito. A presunção de inocência, princípio que informa todo o sistema processual penal, e que está prevista como garantia constitucional, também seria invariável e inevitavelmente fulminada.

Outrossim, como este juízo sempre vem asseverando, não é demais exigir do órgão acusador, a quem se impõe o ônus probandi, a reunião de outros elementos probatórios que não se limitem à mera repetição das declarações dos policiais que efetivaram a prisão do acusado, até porque, como consignado alhures, é natural que estes objetivem legitimar, até inconscientemente, sua própria atuação. Por oportuno, não se pode deixar de registrar, em crimes de natureza diversa do ora apurado, a par dos depoimentos policiais, são em regra produzidos outros elementos de prova, a exemplo de testemunhos de terceiros, oitiva da vítima, com reconhecimento de pessoa e de objeto, etc, o que sem dúvida contribui para a realização de uma instrução processual mais robusta, com possibilidade de uma construção mais sólida da culpabilidade do agente.

Por um outro viés, estes mesmos policiais já dispõem, nos dias atuais, de outros instrumentos e mecanismos aptos a robustecer os motivos ensejadores da prisão e da persecução penal, conferindo às suas declarações um caráter de veracidade quase irrefutável, como já se pôde constatar em outras oportunidades, em que os policiais se valeram, inclusive, de gravações audiovisuais para registrar as abordagens, diligências e operações. Aliás, é pouco compreensível que nos dias de hoje, no estágio em que se encontra a tecnologia, haja ainda uma utilização tão tímida de aparatos e instrumentos de captação e gravação das abordagens policiais.

Pontua-se também, mais uma vez, que não foi trazida qualquer testemunha distinta do policial que pudesse corroborar a versão acusatória, o que certamente robusteceria a prova acusatória. Neste sentido são as palavras do eminente jurista Guilherme de Souza Nucci:

Parece-nos cauteloso que o magistrado, visualizando, em processos de apuração de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, um rol de testemunhas de acusação

formado somente por policiais, indague os mesmos a razão pela qual não se obteve nenhuma pessoa, como testemunha, estranha aos quadros da polícia. Essa verificação é essência, pois uma apreensão de drogas feita à vista de inúmeras pessoas, em local público, por exemplo, pode perfeitamente contar com o testemunho de pessoas que não sejam policiais. (NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 2009, p. 353).

Voltando ao caso em questão, cumpre indagar, ante aquilo que foi exposto, se o quanto relatado pelo policial pode, na hipótese em tela, ser considerada uma prova robusta e coerente para fins de fundamentalmente arrimar uma condenação por tráfico de drogas. No entendimento deste Juízo, não é.

Forçoso, in casu, verificar que, tendo negado o réu Marcos que traficava entorpecentes, e não havendo, além da declaração dos policiais, qualquer outra prova que confirme a prática de tráfico de entorpecente, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo em favor do acusado.

Em sentido semelhante, manifesta-se a jurisprudência:

TÓXICO - Crime de tráfico e associação para o tráfico - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à posse ou propriedade da droga apreendida - Mercancia não comprovada - Indícios insuficientes para formar convicção nesse sentido - Réu preso em companhia de menor reconhecido e indicado como traficante - Ausência de atos seguros e concretos vinculando suas ações - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Dúvida remanescente que autoriza o decreto absolutório - Recurso provido - (TJSP, APELAÇÃO Nº: 990.09.047397-5 - COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA APTE WELLINGTON DA SILVA SANTOS APDO : Ministério Público).

Frise-se, ainda, por oportuno, que sequer houve a vinda aos autos de perícia no celular dos acusados, com conversas entre eles ou com terceiros que indicassem a venda de drogas.

Da mesma forma, não se realizou qualquer perícia dactiloscópica confirmando as digitais do acusado na sacola ou porções que continham as drogas que estavam com o corréu Andrew, indicando que realizavam tráfico conjuntamente.

Assim, a despeito da probabilidade da ocorrência do tráfico de drogas e mesmo que se considere pouco crível a versão apresentada pelo réu Marcos, o conjunto probatório produzido não se mostra firme o bastante para lastrear uma condenação por tráfico de drogas pelo acusado, devendo ser acolhido o pedido ministerial de absolvição de Marcos.

Destarte, nesta fase processual, encerrada a instrução, se alguma dúvida existe deverá ser interpretada em favor do réu, conforme recomenda a boa técnica processual penal.

Como é cediço, em casos de dubiedade, de provas colidentes ou de insuficiência probatória, o respeito à máxima da presunção de inocência impõe a absolvição da acusada como medida de justiça. Sobre a presunção de inocência, manifesta-se Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, vol I. Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2008, p.178/19):

"...é princípio fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que para isso tenha-se que pagar o preço da impunidade de algum culpável. Isso porque, ao corpo social, lhe basta que os culpados sejam geralmente punidos, pois o maior interesse é que todos os inocentes,

sem exceção, estejam protegidos.”

Continua o jurista:

“Se é verdade que os cidadãos estão ameaçados pelos delitos, também o estão pelas penas arbitrárias, fazendo com que a presunção de inocência não seja apenas uma garantia de liberdade e de verdade, senão também uma garantia de segurança (ou de defesa social), enquanto segurança oferecida pelo Estado de Direito e que se expressa na confiança dos cidadãos na Justiça. É uma justiça que se oferece ao arbítrio punitivo”

Assim, mesmo que implique a absolvição de um culpado, a presunção da inocência deve ser integralmente aplicada quando nos autos não subsiste a certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório, sendo certo que muito mais grave e deletério a um Estado Democrático de Direito do que soltar um culpado é impor a um inocente uma condenação penal e submetê-lo aos rigores e amarguras de uma pena privativa de liberdade.

A responsabilidade penal deve estar estreme de dúvidas e não pode ser atribuída a um sujeito de maneira precipitada. É preciso que as provas carreadas aos autos demonstrem de forma inequívoca que o acusado foi do crime, de maneira que seja possível lhe imputar a prática do delito, o que não ocorreu no caso em questão. Fato é que, sem a taxatividade própria do direito penal, impossível exarar decreto condenatório, até mesmo porque:

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação” (Ac. un. da 5a. Câ., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313

No mais, conforme leciona o Procurador de Justiça Fernando de Almeida Pedroso (PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova Penal, 2ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2004, pág. 150), membro do Ministério Público de São Paulo:

“A sentença de conteúdo condenatório exige, para sua prolação, a certeza de ter sido cometido um crime e de ser o acusado o seu autor. A menor dúvida a respeito acena para a possibilidade de inocência do réu, de sorte que a Justiça não faria jus a essa denominação se aceitasse, nessas circunstâncias, um édito condenatório, operando com uma margem de risco – mínima que seja – de condenar quem nada deva.

Quando se tem presente, salientou Malatesta, que a condenação não pode basear-se senão na certeza da culpabilidade, logo se vê que a credibilidade razoável – também mínima – da inocência, sendo destrutiva da certeza da culpabilidade, deve, necessariamente, conduzir à absolvição”.

Com efeito, uma sentença judicial condenatória deve ser embasada em elementos objetivos, contundentes e sólidos. Em verdade, para fins de condenação criminal, a intuição deste julgador não tem qualquer importância. Não basta a crença, deve haver certeza.

Novamente, colaciona-se o escólio do Procurador de Justiça Fernando de Almeida Pedroso (PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova Penal, 2ª ed. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2004, pág. 15):

A respeito, obtempera Heleno Cláudio Fragoso que “a condenação exige certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de nossa mente em torno da existência de certa realidade”. Mesmo a íntima convicção do Juiz – pondera Sabatini –, como sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos de

justificação (g.n.), não é verdadeira e própria certeza (...); no lugar da certeza, em espécie tal, tem-se a simples crença.

O entendimento do nobre membro ministerial é de rara sabedoria e desmerece contestações.

Como se vê, no caso em tela, mesmo diante do encontro do acusado em local próximo de onde o réu Andrew traficava drogas, e considerando o teor dos interrogatórios, as inconsistências apontadas e havendo apenas os testemunhos policiais que são a reprodução das declarações que constam em inquérito, os elementos amealhados no curso da instrução penal não permitem concluir com segurança necessária que o acusado praticava o crime inserto no art. 33, caput c.c. art. 40, VI, da lei 11.343/06.

Portanto, remanescem dúvidas acerca do envolvimento do acusado Marcos com o crime a ele imputado. Saliente-se que do cotejo da prova oral não é possível concluir que Marcos realizava a função de "olheiro" ou era a pessoa que encaminhava usuários ao corréu, ou, ainda, que droga pertencia também ao acusado que a comercializava e teria ganho com .

Em relação ao réu Andrew, contudo, o entendimento é diverso.

Referido acusado, como dito, confessou o delito. E, como já mencionado, os policiais indicaram a forma como foi realizada a abordagem de Andrew, sendo com ele encontrada a quantidade de drogas e anotações de tráfico.

Desse modo, em relação ao acusado Andrew, inexistente qualquer dúvida de sua autoria de delito de tráfico de drogas, impondo-se a condenação por tal delito. Recordar-se que o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, de modo que se consuma com qualquer das outras condutas descritas no mencionado dispositivo legal, como, transportar, trazer consigo, guardar, ter em depósito, entregar a consumo e fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE QUE A PROVA OBTIDA NOS AUTOS É ILÍCITA, E DE QUE O CRIME É IMPOSSÍVEL, POR NÃO TER CHEGADO AO DESTINO, QUE NÃO FORAM VENTILADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDUTA DE TRANSPORTAR OU TRAZER CONSIGO, COM O INTUITO DE FORNECER, AINDA QUE PARA GRATUITO CONSUMO ALHEIO, QUE SE SUBSUME AO TIPO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. [...] 2. "Transportar", "trazer consigo" ou "fornecer ainda que gratuitamente" substância entorpecente ilícita são São Paulo núcleos do tipo do delito de tráfico de drogas - crime de perigo abstrato, de ação múltipla e conteúdo variado, que se consuma com a prática de quaisquer das ações insertas no art. 33 da Lei Antidrogas. (HC 225555/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. em 09/12/2012).

Conforme a folha de antecedentes de fls. 135/136, o acusado é primário, devendo ser reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois o réu ostenta bons antecedentes e inexistente nos autos comprovação suficiente de que se dediquem a atividade criminosa. Demais disso, a diversidade de drogas, embora seja considerável, não obsta o reconhecimento da minorante.

Nesse sentido, o aresto abaixo colacionado.

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Associação para o tráfico de drogas. Recurso ministerial. Pleito de condenação dos apelados como incurso no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06. Provas suficientes de autoria e materialidade apenas em relação ao tráfico. Mantida a absolvição quanto ao delito previsto no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06, ante a ausência de provas no que tange à estabilidade e

permanência do suposto grupo criminoso. Dosimetria das penas. Confirmado o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, no grau máximo. Primariedade, quantidade de droga que não se mostra excessiva e inexistência de elementos que indiquem a dedicação à atividade criminosa ou integração a organização voltada à prática de delitos. Regime inicial aberto e substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos mantidos nos termos da r. sentença. Evidente erro material na r. sentença em relação às penas de multa. Viável a sua correção. Negado provimento ao recurso, com correção, de ofício, do erro material constante do dispositivo da r. sentença. (TJSP; Apelação 0046355-59.2016.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/07/2017; Data de Registro: 12/07/2017) (grifos nossos)

Quanto ao delito de associação para fins de tráfico, não há provas que apontem para a culpabilidade dos acusados.

O próprio órgão acusador requereu a improcedência em relação a tal delito.

Com efeito, o crime do art. 35 da lei 11.343/2006 é uma espécie de quadrilha ou bando específico do tráfico ilícito de entorpecentes, exigindo para a sua configuração a comprovação de sua permanência. Afirma Guilherme de Souza Nucci (2009, p.365):

“Demanda-se prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa.” E mais: “exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no animo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática de crime de tráfico.”

No caso em testilha, não tendo sido comprovado o caráter de estabilidade e permanência da associação dos réus, que afirmam que não se conheciam, não há como se imputar aos acusados a prática do crime em questão, sendo de rigor a absolvição dos acusados em relação ao delito apontado.

No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE APONTAVAM NOMINALMENTE AS PESSOAS DOS RÉUS COMO TRAFICANTES - APREENSÃO DA DROGA EM LOCAL PRÓXIMO - ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - TESES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - RECURSO MINISTERIAL - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO - MANUTENÇÃO - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 - POSSIBILIDADE. - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se de qualquer outra testemunha fossem, eis que prestam compromisso e estão sujeitos às penalidades legais pelo falso, mostrando-se hábeis, portanto, a confirmar os fatos expostos no flagrante e comprovar a autoria delituosa. - Tendo os policiais recebido denúncia anônima apontando as pessoas dos réus como traficantes, e sendo eles abordados em lugar conhecido como ponto de venda de drogas, apreendida em local próximo elevada quantidade de entorpecentes, deve ser mantida a condenação. - Para caracterização do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/06, deve ser comprovada a estabilidade e permanência do vínculo associativo, não demonstradas no presente caso, mantendo-se a absolvição declarada na sentença. (TJ-MG - APR: 10079073229183001 MG, Relator: Delmival de Almeida Campos, Data de Julgamento: 15/05/2013, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/05/2013)

No que se refere ao delito de resistência, de rigor a absolvição do acusado Andrew, como aliás requerido pelo próprio Ministério Público, uma vez que não restou elucidado, pelo teor da prova oral, qual foi o efetivo ato de resistência que teria

sido praticado por Andrew em face dos policiais.

Deveras, o acusado Andrew, conforme fls. 58, possuía após a prisão "equimose roxa em pálpebra inferior esquerda com edema traumático em região zigomática".

Em interrogatório judicial, Andrew afirmou ter sido vítima de agressão por policiais quando abordado, alegando que "no dia que foi preso, não reagiu a princípio quando os policiais chegaram. Não correu e foi algemado pelo policial, falando que não sabia onde era a "casa bomba" o policial chutou suas pernas e caiu no chão, batendo o rosto no chão, motivo pelo qual chutou o policial também e apareceu outro policial e o pegou pelo pescoço, aí o outro policial lhe bateu e deu um chute nele.".

O que se infere do que foi amealhado nos autos é que o acusado acabou lesionado pelos policiais quando abordado, razão pela qual teria revidado a agressão, o que não pode ser entendido como resistência a ato legal, mas sim, eventual legítima defesa pelo réu Andrew.

Portanto, deve o réu Andrew ser absolvido do delito de resistência, por ausência de prova de seu cometimento.

No que tange ao delito de tráfico de drogas por Andrew, inexistente qualquer causa excludente de ilicitude ou que isente o réu de pena.

No mais, a ação foi culpável, reprovável, pois o réu era (e ainda é) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado ANDREW VINICIUS DE ALMEIDA SANDIM, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, §4, da Lei 11.343/06, ABSOLVENDO-O, todavia, das imputações relativas aos delitos do art. 35, da Lei de Drogas e do delito do art. 329, do CP, com fulcro no art. 386, VII, do CPP; ABSOLVO, do mesmo modo, o réu MARCOS HENRIQUE CAMPANA DA CRUZ, qualificado nos autos, de todas as imputações que lhe foram dirigidas, o que também faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Circunstâncias judiciais

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena do acusado Andrew pelo delito de tráfico de drogas privilegiado.

Assim, primeiramente, no tocante às circunstâncias judiciais, verifico que o réu agiu com a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar nesse sentido. Não há nos autos elementos concretos que permitam uma valoração da sua personalidade. O réu não possui maus antecedentes (fls. 41/43 e 135/136). O motivo do delito se constituiu pela obtenção do lucro fácil, que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. Nada há, em concreto, que desabone a sua conduta social. As consequências do crime não se mostraram de maior monta. As circunstâncias também não se revelam desfavoráveis ao acusado, lembrando que a quantidade e natureza da droga não apresentam expressão ou magnitude aptas a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Diante de tais considerações fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 dias-multa, no menor valor legal.

Na segunda fase não incidem agravantes.

Incide a atenuante da confissão, contudo, diante da Súmula 231 do STJ, deixo de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Incide a causa de diminuição de pena, fazendo jus o réu à aplicação do redutor do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, no patamar de 2/3, passando a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa.

Neste ponto, vale mencionar a manifestação de César Dário Mariano:

Presentes os requisitos previstos na norma a diminuição da pena é obrigatória, não ficando ao alvedrio do Juiz operar a redução ou não. Embora a norma empregue a expressão “as penas poderão ser reduzidas”, não se trata de atividade discricionária do Juízo, mas de direito subjetivo do acusado. Aliás, a primariedade e bons antecedentes deverão ser demonstrados pelo acusado, ao passo que caberá ao Ministério Público o ônus de provar que o réu se dedica à atividade criminosa ou que pertence à organização criminosa. Não cabe ao réu a prova de fatos negativos, mas a quem alega, no caso, o Ministério Público.

(...) Dedicar-se a atividades criminosas pressupõe reiteração de condutas tipificadas como crime, ou seja, habitualidade no cometimento de delitos. Tal circunstância poderá ser demonstrada por meio de folhas de antecedentes criminais, certidões cartorárias, cópias de outros processos, testemunhas, ou seja, qualquer meio hábil a provar a vida criminosa do acusado. Como a norma não diz qual espécie de atividade criminosa poderá ser qualquer uma, desde que, obviamente, não se trate de delitos culposos, que pressupõem ausência de vontade.

A norma visa a impedir a redução da pena para aquele que de forma habitual e deliberada pratica qualquer espécie de crime. Com efeito, aquele que faz da vida criminosa seu modo de vida não é merecedor do redutor. (Silva, César Dario Mariano da Lei de drogas comentada / César Dario Mariano da Silva. -- 2. ed. -- São Paulo : APMP - Associação Paulista do Ministério Público, 2016).

Em sentido semelhante:

“A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).

Ainda, é preciso salientar que com o acusado não foi encontrado qualquer tipo de armamento, ou quantia mais expressiva em dinheiro e o crime, ao que consta, não envolveu qualquer tipo de ameaça, violência ou intimidação.

Outrossim, a quantidade de drogas, a par de não ser elemento suficiente a afastar a minorante, também não o é para modular a fração do benefício.

Nesse sentido, o recente julgado do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA E, PORTANTO, NÃO SE PRESTAM PARA JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAR A FRAÇÃO DESSE BENEFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (RECURSO ESPECIAL Nº 1925096 – SP – RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ – Brasília, 02 de agosto de 2021). (grifos nossos).

Do mesmo modo, o fato de o réu possuir um processo criminal em andamento (fls. 135/136), sem condenação transitada em julgado, não pode obstar a aplicação do

redutor. A propósito:

Aliás, por ocasião do julgamento do HC n. 602.611/DF (Rel. Ministro Rogerio Schietti), ocorrido em 17/11/2020, esta colenda Sexta Turma, à unanimidade, seguiu a compreensão do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria (com a minha ressalva pessoal) e, assim, reconheceu a incidência do redutor em favor de réu que havia tido o benefício negado com base, tão somente, em processos em andamento e condenação ainda não transitada em julgado. Diante de tais considerações, firme na importância de se observarem os precedentes e de se adotar interpretação uniforme das leis - até para garantir uma ordem jurídica mais coerente, mais estável e com maior previsibilidade quanto à interpretação adotada pelo Poder Judiciário -, curvo-me ao posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, para reconhecer a inidoneidade do segundo fundamento apontado no caso para justificar a impossibilidade de incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em favor do paciente, qual seja, a existência de processos ainda em andamento. Portanto, à ausência de fundamento suficiente o bastante para justificar o afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, deve a ordem ser concedida, inclusive liminarmente, a fim de aplicar, em favor do réu, o referido benefício. ((STJ - HC: 749417 ES 2022/0183000-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 20/06/2022)).

Nesse contexto, à míngua de outras causas modificadoras, fica o réu ANDREW VINÍCIUS DE ALMEIDA SANDIM definitivamente condenado por tráfico de drogas privilegiado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, cumulada com 166 dias-multa, no mínimo legal, pena esta que torno definitiva.

Do regime inicial de cumprimento de pena e alternativas penais:

O parágrafo 4º do art. 33 da lei 11.343/06 de forma louvável, admitiu em casos como o ora analisado, a possibilidade de redução da pena imposta ao acusado primário e de bons antecedentes em até 2/3. A previsão legal de uma causa de diminuição de pena nestas circunstâncias tratou de prestigiar da forma adequada o princípio constitucional da individualização da pena, reconhecendo uma situação fática que salta aos olhos do operador do direito: o de que traficantes eventuais, de bons antecedentes e que nunca se envolveram em organizações criminosas não podem ser equiparados aos grandes comerciantes de drogas, verdadeiros empresários do tráfico, responsáveis por manter toda uma rede articulada de produção e distribuição de drogas, auferindo grandes lucros da atividade e fomentando o cometimento de outros tantos delitos graves. Como se vê, são duas espécies distintas de criminosos a justificar tratamentos diversos pela lei penal.

Estranhamente, o próprio dispositivo legal supra aludido, de forma incongruente, negava expressamente a possibilidade de substituição da pena privativa em pena restritiva de direito, afastando-se, desta feita, dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, e, como tal, do próprio princípio da individualização da pena que, de início, parecia pretender alcançar.

Não há dúvida, como mencionado alhures, que a reprovabilidade da conduta do traficante ocasional é menor do que a dos grandes traficantes de droga responsáveis por coordenar e alimentar a grande cadeia do tráfico ilícito de entorpecentes. Eis a razão pela qual a nova lei de drogas, de forma feliz, reconheceu a culpabilidade atenuada daqueles pequenos criminosos, permitindo uma razoável diminuição da pena que eventualmente lhe venha a ser imposta.

Todavia, a concretização da máxima da individualização da pena não se esgota na dosagem da quantidade de pena aplicada ao réu, mas também se funda na determinação de sua qualidade ou natureza. Se a culpabilidade do réu é de menor grau, sustentando a lei uma diminuição da pena imposta, não subsiste razão jurídica para

obstar ao réu a concessão de benefícios penais condizentes com a sua menor culpabilidade.

A substituição da pena privativa por restritiva de direito é mecanismo salutar e consentâneo com os primados do Estado Democrático de Direito em que vivemos, sendo, em caso como ora apresentado, bastante a demonstrar a reprovação do Estado com relação à conduta perpetrada pela agente, evitando-se assim os males que o sistema carcerário acarreta, mormente